

1501933-48.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... instituições de ensino, basta que o agente pratique o tráfico ilícito de droga na proximidade física do local.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino (art. 40, III, da Lei 11.343/06) enseja a aplicação da majorante, sendo despidiende a prova de que o ilícito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501933-48.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2344888/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22032518 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3638/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2344888 - 02º D.P. PIRACICABA,

3638/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS WESLEY BUENO NAZARIO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 02 dias do mês de maio de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) CARLOS WESLEY BUENO NAZARIO. Ausentes as testemunhas arroladas pela defesa: Silvio de Oliveira Campos, Maria Regina Addad Ramiro e Kauã Denilson Bueno de Farias.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, pelo Promotor de Justiça foi requerida a palavra, tendo assim se manifestado:

"MM.Juíza, CARLOS WESLLEY BUENO NAZARIO foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta de 11h43m, na rua Escolástica Couto Aranha, esquina com a rua Querubim Sampaio, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, trazia consigo 73 porções de "crack", 42 porções de "maconha" e 27 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

PRELIMINARMENTE: DO ADITAMENTO DA DENUNCIA.

Adito a denúncia para fazer constar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta de 11h43m, , nas proximidades da "Escola Estadual Helio Nerin", na rua Escolástica Couto Aranha, esquina com a rua Querubim Sampaio, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, CARLOS WESLLEY BUENO NAZARIO, qualificado a fls. 05, trazia consigo 73 porções de "crack", 42 porções de "maconha" e 27 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, guardas passavam pelo local, que fica a cinquenta metros aproximadamente da "Escola Estadual Helio Nerin", quando avistaram e suspeitaram do denunciado, que estava "aparentemente negociando algo" com outro indivíduo. Ao perceber a aproximação, eles evadiram-se em direções distintas.

O denunciado foi abordado e na sua posse foi apreendida uma sacola, que estava nas vestes íntimas, onde foi localizada a droga acima mencionada e a quantia de R\$ 101,00. Instado, informalmente, confessou a mercancia ilícita, inclusive que "vendia a porção de cocaína a R\$ 20,00 e as porções de "crack e maconha" a R\$ 5,00 cada.

Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Diante das circunstâncias apuradas, apreensão de significativa quantidade e variedade de porções individualizadas e de dinheiro de origem não comprovada, além da confissão informal do denunciado, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Ante o exposto denuncio CARLOS WESLLEY BUENO NAZARIO como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, seja instaurada a ação penal com o rito previsto nos artigos 56 e seguintes da mesma lei, citando os denunciados a apresentar defesa, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, seguindo até final procedência e condenação.

A Defensora manifestou-se em relação ao aditamento ora formulado, conforme gravação no Teams.

Pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Considerando o endereço mencionado na denúncia (Rua Escolástica Couto Aranha esquina com a Rua Querubim Sampaio), bem como que a escola Prof.Hélio Nehring encontra-se à rua Escolástica Couto Aranha nº 170, é caso de recebimento do aditamento, sendo necessário a verificação do cabimento da causa de aumento quando da prolação da sentença.

Assim, recebo o ADITAMENTO ORA OFERTADO, dando o réu como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia providenciar as comunicações e anotações que se fizerem necessárias.

Pela defensora foi dito que desiste da oitiva das testemunhas Silvio, Maria Regina e Kauã.

Pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Homologo a desistência da Defesa em relação às testemunhas Silvio de Oliveira Sampaio, Maria Regina Addad Ramiro, Kauã Denilson Bueno de Farias.

A seguir, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) interrogatório do réu, pelo sistema virtual.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

CARLOS WESLLEY BUENO NAZARIO foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta de 11h43m, na rua Escolástica Couto Aranha, esquina com a rua Querubim Sampaio, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, trazia consigo 73 porções de "crack", 42 porções de "maconha" e 27 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

PRELIMINARMENTE: DO ADITAMENTO DA DENUNCIA.

Adito a denúncia para fazer constar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta de 11h43m, , nas proximidades da "Escola Estadual Helio Nerin", na rua Escolástica Couto Aranha, esquina com a rua Querubim Sampaio, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, CARLOS WESLLEY BUENO NAZARIO, qualificado a fls. 05, trazia consigo 73 porções de "crack", 42 porções de "maconha" e 27 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, guardas passavam pelo local, que fica a cinquenta metros aproximadamente da "Escola Estadual Helio Nerin", quando avistaram e suspeitaram do denunciado, que estava "aparentemente negociando algo" com outro indivíduo. Ao perceber a aproximação, eles evadiram-se em direções distintas.

O denunciado foi abordado e na sua posse foi apreendida uma sacola, que estava nas vestes íntimas, onde foi localizada a droga acima mencionada e a quantia de R\$ 101,00. Instado, informalmente, confessou a mercancia ilícita, inclusive que "vendia a porção de cocaína a R\$ 20,00 e as porções de "crack e maconha" a R\$ 5,00 cada.

Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Diante das circunstâncias apuradas, apreensão de significativa quantidade e variedade de porções individualizadas e de dinheiro de origem não comprovada, além da confissão informal do denunciado, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Ante o exposto denuncio CARLOS WESLLEY BUENO NAZARIO como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, seja instaurada a ação penal com o rito previsto nos artigos 56 e seguintes da mesma lei, citando os denunciados a apresentar defesa, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, seguindo até final procedência e condenação.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, guardas passavam pelo local, quando avistaram e suspeitaram do denunciado, que estava "aparentemente negociando algo" com outro indivíduo. Ao perceber a aproximação, eles evadiram-se em direções distintas.

O denunciado foi abordado e na sua posse foi apreendida uma sacola, que estava nas vestes íntimas, onde foi localizada a droga acima mencionada e a quantia de R\$ 101,00. Instado, informalmente, confessou a mercancia ilícita, inclusive que "vendia a porção de cocaína a R\$ 20,00 e as porções de "crack e maconha" a R\$ 5,00 cada.

Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Diante das circunstâncias apuradas, apreensão de significativa quantidade e variedade de porções individualizadas e de dinheiro de origem não comprovada, além da confissão informal do denunciado, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A testemunha Felipe Vieira Alves, guarda municipal, narrou estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido pela venda de drogas, há aproximadamente 50 metros da Escola Estadual Helio Nerin, quando avistaram dois indivíduos próximos um do outro (um deles vestia camiseta vermelha e outro bermuda e camiseta preta), aparentemente negociando algo. Com a aproximação da guarnição os indivíduos se dispersaram, sendo que o indivíduo que trajava uma bermuda e camiseta preta, saiu andando rapidamente com as mãos na frente, indicando segurar algo. Diante da atitude suspeita, efetuaram a abordagem e em busca pessoal, sendo o indivíduo identificado como CARLOS WESLEY BUENO NAZARIO, envolto em uma sacola plástica, no interior de suas vestes íntimas, localizaram 73 porções de substância aparentando ser crack, bem como 42 porções de substância aparentando ser maconha e 27 trouxinhas de análoga a cocaína, além da quantia de R\$ 101,00. Questionado, o indivíduo confessou a traficância, alegando que acabara de chegar no local para iniciar as vendas, sendo que cada porção de cocaína era vendida por R\$ 20,00, ao passo que as porções de crack e maconha eram comercializadas a R\$ 5,00. Em relação ao outro indivíduo, que trajava uma camiseta vermelha, não lograram abordá-lo. Assim, deram voz de prisão ao indivíduo, o qual foi conduzido perante a autoridade policial, sendo necessário o uso de algemas, dado o receio de fuga" (fls. 03).

DA PROVA NA FASE JUDICIAL:

O GCM Felipe Vieira Alves narrou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido pela venda de drogas, perto da Escola Estadual Helio Nerin, quando viu dois indivíduos conversando. Estavam apenas os dois no local e o réu entregou algo ao outro. O de camisa vermelha tomou sentido oposto e não foi possível abordá-lo. O réu, quando viu a viatura, colocou as mãos na frente, na linha da cintura, indicando segurar algo, e foi abordado. Encontrou com ele, no interior de suas vestes, na linha da cintura, uma sacola plástica com porções de crack, maconha e cocaína, além de R\$ 101,00. Ele confessou a traficância, alegando que acabara de chegar no local para iniciar as vendas. Não foi possível identificar o que o réu entregou ao outro indivíduo. A cocaína era vendida a R\$ 20,00 e as porções de crack e maconha eram vendidas a R\$ 5,00. Tudo isso foi o réu quem informou. Conhecia o réu, pois já o havia visto nas imediações, mas nunca o tinha abordado.

No mesmo sentido, o GCM Willian José Santos Junior, o qual acrescentou que o réu disse também que a pessoa com quem conversava era um comprador de entorpecentes. Confirmou que o local é próximo a uma escola. E que o réu, ao ser indagado o que fazia "da vida", respondeu que "nada".

Interrogado em juízo, o réu alegou que é usuário de drogas desde 13 anos de idade. No dia dos fatos foi comprar um cigarro de maconha, entregou dinheiro ao moleque, que gritou "moiou" e correu. Foi enquadrado por Willian e seu parceiro e preso. Próximo a um cano puxaram uma sacola e disseram que a droga era sua. Consigo só foi apreendida uma "paranga de maconha", um isqueiro e vinte reais em dinheiro. Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito em questão.

Os guardas foram firmes e uníssonos ao confirmarem que passavam pelo local, que fica a aproximadamente cinquenta metros da "Escola Estadual Helio Nerin", quando avistaram o réu em atitude suspeita, tendo em vista que estava "aparentemente negociando algo" com terceira pessoa não identificada. Ao perceberem a aproximação, eles evadiram-se do local. O réu foi abordado e com ele encontraram uma sacola contendo 73 porções de crack, 42 porções de maconha e 27 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 101,00. Instado, informalmente, ele confessou que "vendia a porção de cocaína a R\$ 20,00 e as porções de "crack e maconha" a R\$ 5,00 cada".

Pertinente salientar, que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas civis, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam

retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso

A significativa quantidade de droga apreendida, diversidade e modo de acondicionamento, corroborada pelas palavras dos guardas civis não deixam dúvidas de que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita.

Destarte, imperiosa a condenação do réu pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena pode ser fixada no mínimo legal, pois ausentes circunstâncias desabonadoras do artigo 59, do Código Penal.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

O delito foi praticado nas imediações da escola estadual “Helio Nerin”, razão pela qual a pena deverá ser majorada.

Ressalta-se que a majorante deverá ser reconhecida ainda que o local não estivesse em funcionamento no momento do delito.

Isso porque, ao elaborar a referida norma, o legislador não dispôs sobre a finalidade da venda ser destinada aos alunos, mas sim o fez em razão de sua maior reprovabilidade, bem como visando dar maior proteção a tais pessoas, que acabam sendo mais suscetíveis à atuação criminosa.

Dessa forma, prescindível que, no momento da prática delitiva, a escola estivesse em funcionamento, pois a intenção do legislador foi punir de forma mais rigorosa aqueles que agem com tamanha ousadia e desvirtuamento.

Nesta esteira, para o reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, referente às instituições de ensino, basta que o agente pratique o tráfico ilícito de droga na proximidade física do local.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino (art. 40, III, da Lei 11.343/06) enseja a aplicação da majorante, sendo despicienda a prova de que o ilícito visava atingir os frequentadores desse local.” (AgRg no REsp 1558551/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

“Para a incidência da causa especial de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, basta que a atividade delitiva venha a ocorrer em localidade mais próxima aos estabelecimentos de ensino, dispensando-se a comprovação de que a clientela constitui-se de estudantes. O aumento decorre, conforme posição pacífica desta Corte Superior, exclusivamente da localidade em que praticado o delito, em razão da exposição de pessoa que merecem especial proteção ao risco inerente à atividade delitiva. Precedentes”.

(AgRg no REsp 1.398.519/SP, 5ª Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.04.15, DJe. 15.05.2015).

Deste modo, é caso de incidência de um sexto.

A quantidade e diversidade de entorpecente apreendida em poder do réu demonstram que ele se dedicava ao crime. Portanto, não se tratou de conduta isolada, mas contumaz.

Vale ressaltar que, no tocante ao requisito da dedicação às atividades criminosas, é cediço que alguns fatores podem denotar habitualidade e envolvimento no crime, o que impede reconhecimento da figura na modalidade privilegiada.

Um dos exemplos é a quantidade de entorpecente apreendida que evidencia dedicação do réu à mercancia ilícita e maior reprovabilidade da conduta não eventual, devendo ser devidamente combatida e punida pela gravidade do delito, maior reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido temos o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“TRÁFICO DE DROGAS Autoria e materialidade delitivas incontestas – Prova cabal a sustentar o édito condenatório Absolvição Impossibilidade Pleito da acusação visando à reforma parcial da r. sentença Acolhimento Necessário aumento das penas em virtude da quantidade de droga apreendida. Imperioso afastamento do privilégio em face do profissionalismo na atividade criminosa. Recurso defensivo não provido, e provido o apelo ministerial. (Apelação nº 0024057-06.2011.8.26.0032, Rel. Des.

Ivo de Almeida, 1ª Câmara de Direito Criminal, Dj. 23/05/2016) ”.

Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para adequada prevenção e reprovação, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o réu iniciar o desconto da pena no regime inicial fechado.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Presentes os requisitos da prisão preventiva devrá ser indeferido apelo em liberdade.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, Carlos Wesley Bueno Nazario foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 97-99), no dia 19 de dezembro de 2021, por volta de 11h43, na rua Escolástica Couto Aranha, esquina com a rua Querubim Sampaio, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Carlos trazia consigo 73 porções de "crack", 42 porções de "maconha" e 27 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, guardas passavam pelo local, quando avistaram e suspeitaram do réu, que estava "aparentemente negociando algo" com outro indivíduo. Ao perceber a aproximação, eles evadiram-se em direções distintas. O réu foi abordado e na sua posse foi apreendida uma sacola, que estava nas vestes íntimas, onde foi localizada a droga acima mencionada e a quantia de R\$ 101,00. Instado, informalmente, confessou a mercancia ilícita, inclusive que "vendia a porção de cocaína a R\$ 20,00 e as porções de 'crack e maconha' a R\$ 5,00 cada."

Interrogado em solo policial, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 5).

Felipe Vieira Alves, guarda municipal, narrou que: "estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido pela venda de drogas, há aproximadamente 50 metros da Escola Estadual Hélio Nerin, quando avistaram dois indivíduos próximos um do outro (um deles vestia camiseta vermelha e outro bermuda e camiseta preta), aparentemente negociando algo. Com a aproximação da guarnição os indivíduos se dispersaram, sendo que o indivíduo que trajava uma bermuda e camiseta preta saiu andando rapidamente com as mãos na frente, indicando segurar algo. Diante da atitude suspeita, efetuaram a abordagem e em busca pessoal, sendo o indivíduo identificado como Carlos Wesley Bueno Nazario, envolto em uma sacola plástica, no interior de suas vestes íntimas, localizaram 73 porções de substância aparentando ser crack, bem como 42 porções de substância aparentando ser maconha e 27 trouxinhas de análoga a cocaína, além da quantia de R\$ 101,00. Questionado, o indivíduo confessou a traficância, alegando que acabara de chegar no local para iniciar as vendas, sendo que cada porção de cocaína era vendida por R\$ 20,00, ao passo que as porções de crack e maconha eram comercializadas a R\$ 5,00. Em relação ao outro indivíduo, que trajava uma camiseta vermelha, não lograram abordá-lo. Assim, deram voz de prisão ao indivíduo, o qual foi conduzido perante a autoridade policial, sendo necessário o uso de algemas, dado o receio de fuga" (fls. 3). No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Willian José Santos Junior (fls. 4).

Às fls. 27, juntada certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido.

Às fls. 155-164, manutenção da negativa de ANPP.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9-10, fotografia de fls. 11, laudo de constatação de fls. 13-15, laudo de exame definitivo de fls. 89-91.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, Felipe Vieira Alves, guarda municipal. Durante o patrulhamento, viram duas pessoas conversando e aparentemente negociando algo.

Viram o réu entregar algo à outra pessoa. Resolveram abordar. O outro indivíduo fugiu. O réu estava com uma sacola com drogas e dinheiro na cintura, nas vestes íntimas. O réu informalmente confessou a traficância. Disse que vendia a cocaína a R\$20,00 a porção, maconha e crack eram vendidos a R\$5,00/porção. [Descrever a ação de Carlos ao ser visto na negociação] O réu entregou algo, não sabe dizer o quê, e voltou a sua mão na linha da cintura. Já havia observado Carlos nas imediações, mas nunca tinha abordado. [O réu disse algo sobre o dinheiro?] Não precisou se era decorrente da venda de drogas, mas acredita que sim. No local da abordagem, somente estavam os 2 indivíduos, era próximo a uma esquina.

b) Em seguida, ouvido o guarda municipal Willian José Santos Junior. Estava em patrulhamento próximo ao colégio estadual, conhecido pela traficância. Próximo, viram Carlos, de camiseta preta, e um indivíduo de camiseta vermelha conversando. Carlos entregou algo ao outro indivíduo. Ao avistarem a viatura, ambos se evadiram. Carlos levou a mão na região da cintura. Conseguiram abordar Carlos. Na região da sua cintura, havia uma sacola plástica com 73 porções de crack, 42 porções de maconha e 27 de cocaína, e R\$101,00. Questionado, Carlos informou que estava no local vendendo drogas e que havia chegado a pouco tempo. Sobre a outra pessoa, disse que era um comprador. Conhecia o réu de vista, pois sempre o viam na região, mas nunca o tinha abordado. [O réu disse algo sobre o dinheiro?] Não se recorda, mas se lembra que o réu disse que não trabalhava e acredita que era proveniente da venda de entorpecentes.

c) Por fim, foi interrogado o réu Carlos Wesley Bueno Nazario. Perguntado sobre trabalho, explicou que atuava como sushiman. Explicou que fuma maconha desde os 13 anos. Não conseguia parar. Nunca teve envolvimento com tráfico. Foi levar o irmão na escola, deixou-o e, quando foi embora, passou na biqueira para comprar um cigarro de maconha. O traficante, de repente, saiu correndo e gritou "moiô". Foi em direção a um aterro, conhecido como "terrão". Já conhecia os guardas, que o enquadravam. Em uma dessas abordagens, ameaçaram-no em frente do irmão e da mãe e disseram que, se o pegassem com cigarro ou maconha, iam prendê-lo até o final do ano. A mãe protestou, disse que era absurdo, e os guardas entraram na viatura e saíram contrariados. No dia dos fatos, ele foi surpreendido pelos guardas logo após adquirir um cigarro de maconha. O guarda Felipe Vieira disse "tá vendo, eu disse que ia te prender nesse ano se te pegasse com cigarro ou paranga". Depois que lhe colocaram no camburão, saíram com a viatura, foram para outra rua, saíram em buscas e, perto do "Ducha Lanches", enfiaram a mão em um cano e pegaram uma sacola - que viu ter as drogas que lhe imputaram. Era viciado em maconha, passava mal se não fumasse - ao ser preso, foi muitas vezes para a enfermaria. Não tem nada contra os guardas, mas eles lhe ameaçaram para que parasse de fumar maconha; chegou a falar aos guardas que um dos tios estava estudando para prestar concurso para a PM, e eles responderam que poderiam "mexer os pauzinhos" para que esse tio fosse preso também.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal. Não bastasse, a atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, também é ilícita. Dessa maneira, a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação da Guarda Civil Municipal.

Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à

abordagem, eis que, conforme relatado pelos guardas municipais, logo após a visualização do imputado, eles efetuaram a abordagem imediatamente por considerarem que o réu e terceira pessoa não identificada estavam “negociando alguma coisa” e, ao visualizarem a viatura, teriam “se evadido em direções diferentes”. Os guardas sequer visualizaram a prática de qualquer atividade relacionada ao tráfico. O averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância.

E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal, atividade típica de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelar.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido.

Para melhor ilustrar, cite-se o habeas corpus n. 470.937-SP, em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a revista pessoal efetuada por agente de segurança privada. Extraí-se do referido julgado, aplicável ao presente caso por analogia, que, tal como os seguranças privados, os guardas municipais poderiam ter efetuado a custódia do indivíduo, atuando como “qualquer do povo” (CPP, art. 301), mas não a sua revista pessoal (HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157). E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao denunciado.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU SUBSIDIARIAMENTE, PELA DESCLASSIFICAÇÃO
Caso se entenda pela licitude da atuação da GCM, de rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos guardas, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP

e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações deles são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decreta sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

No mais, caso se entenda pela comprovação de um delito, é certo que há nos autos somente a prova de que o réu estava com uma porção de maconha, característica de uso de entorpecentes. Isso posto, subsidiariamente, se requer a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Caso não conhecida a preliminar, e considerando a confissão informal do acusado, passo a me manifestar acerca da dosimetria da pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, há que se reconhecer a menoridade e a confissão, ainda que apenas a informal e mesmo que a pena não sofra alteração.

c) Do afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da LD

Não restou comprovado nos autos que o local em que o réu foi preso está próximo de uma escola a ponto de aplicação da causa de aumento. Também não há prova nos autos de que estudantes era visados na suposta traficância.

Não é o caso, portanto, de sua aplicação.

d) Da aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD, pois estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo. Conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto. Caso o privilégio seja reconhecido, requer seja fixado regime aberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Finalmente, reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução

por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

CARLOS WESLEY BUENO NAZARIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de dezembro de 2021, por volta de 11h43, na rua Escolástica Couto Aranha, esquina com a rua Querubim Sampaio, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, trazia consigo 73 porções de “crack”, 42 porções de “maconha” e 27 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas passavam pelo local, que fica a cinquenta metros aproximadamente da “Escola Estadual Helio Nering”, quando avistaram e suspeitaram do réu, que estava “aparentemente negociando algo” com outro indivíduo. Ao perceber a aproximação, eles evadiram-se em direções distintas.

O réu foi abordado e na sua posse foi apreendida uma sacola, que estava nas vestes íntimas, onde foi localizada a droga acima mencionada e a quantia de R\$ 101,00.

Instado, informalmente, confessou a mercancia ilícita, inclusive que “vendia a porção de cocaína a R\$ 20,00 e as porções de “crack e maconha” a R\$ 5,00 cada.

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio.

Diante das circunstâncias apuradas, apreensão de significativa quantidade e variedade de porções individualizadas e de dinheiro de origem não comprovada, além da confissão informal do réu, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida (fls. 100/101) sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 102/103). Notificado (fls. 108), o réu apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e o envio dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, para manifestação acerca da oferta de acordo de não persecução penal. No mérito, alegou inocência (fls. 112/117).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls. 135/138). O réu foi citado (fls. 169).

O Procurador-Geral de Justiça insistiu no não oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 155/164).

Durante a instrução, na primeira audiência, foram ouvidas 02 testemunhas comuns (fls. 170/173). Na segunda audiência, o Ministério Público aditou a denúncia, o que foi recebido, e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

Arguiu a Defesa a nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, com revista pessoal, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que apenas abordaram o réu, que estava em ponto de venda de drogas, em conduta de troca.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, o réu foi abordado na posse da droga, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 421.954/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Da mesma forma, a Sexta Turma do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. [...] 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). 5. Habeas corpus não

conhecido. (HC 286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição com fulcro no inciso VI, do art. 386, do CPP - Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - Provas ilícitas - Inocorrência - Precedente STF e TJSP - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Condenação que se impõe - Causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas devida no patamar mínimo - Imposição de regime inicial fechado - Recurso provido, portanto. (TJSP; Apelação 0001473-09.2016.8.26.0536; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 30/10/2018).

PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. O fato de a prisão do acusado em flagrante ter sido efetuada por guardas municipais em serviço não implica em nulidade do processo. Não demonstração de prejuízo à defesa. Inexistência de abuso ou ilegalidade na diligência realizada. Disposição do artigo 301 do Código de Processo Penal que não é afastada pela norma do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Pelo contrário, a condição de agentes públicos corrobora a idoneidade dos atos dos guardas municipais. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Acusado preso em flagrante delito tendo em depósito, em conjunto com adolescente, de 19 porções de cocaína. Guardas confirmaram a apreensão dos entorpecentes e dinheiro. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal, ausentes circunstâncias exasperantes. Inexistência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Mantida a majorante relativa ao artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, ante a comprovação do envolvimento de adolescente na traficância. Afastada a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da mesma Lei nº 11.343/06, diante da frágil comprovação quanto à natureza das atividades desenvolvidas no estabelecimento indicado na denúncia e de sua proximidade em relação ao local da traficância. Pena redimensionada para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa mínimos. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. Demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se de rigor o perdimento do valor apreendido por ocasião da prisão flagrancial, por se tratar de produto do crime, ao que se soma a ausência de demonstração da sua origem lícita. REGIME. Manutenção do regime inicial fechado. Gravidade concreta do delito diante da natureza da droga apreendida, bem como o envolvimento de adolescente na prática. BENEFÍCIOS. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis penal, anotada a insuficiência da repressão delitiva caso concedida qualquer dessas benesses. Rejeição da preliminar e, no mérito, recurso defensivo provido parcialmente para redução da pena. (TJSP; Apelação 0012875-56.2016.8.26.0320; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de Registro: 11/10/2018 - grifei).

II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, na fotografia de fls. 11, no laudo de constatação de fls. 13/15, bem como no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 89/91, segundo o qual foram detectadas cocaína e Tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05/06).

Em Juízo, o réu afirmou que fuma maconha e cigarro desde a adolescência. Foi levar seu irmão à escola e foi comprar um cigarro de maconha para ele. Pegou o cigarro de maconha e o traficante gritou "moiô". O moleque correu para o terraço e os guardas civis que já o tinham enquadrado outras vezes fumando maconha e já o tinham jurado

de prisão, o abordaram. Os mesmos guardas civis já tinham o abordado na frente de sua casa e dito que iriam prendê-lo, se o encontrassem com maconha. Foi abordado e colocado na viatura, apenas com um cigarro de maconha. Depois, os guardas civis foram até um local, perto da escola, e pegaram mais drogas de dentro de um cano de água, na rua. o guarda Felipe disse: "não falei que se o abordasse de novo iria te prender?". Essa droga foi colocada dentro da viatura. Quando foi abordado, estava perto da escola. Os guardas civis viram que o moleque correu, mas mesmo assim, o prenderam. Com ele, os policiais encontraram um maço de cigarro, sua carteira com seus documentos, R\$ 20,00, uma porção de maconha e um isqueiro. O resto da droga foi encontrado em outro lugar. Faz uso de maconha e não conseguia ficar sem consumi-la. já conhecia os guardas civis e nada tem contra eles, embora já o tivessem abordado. Felipe e Miranda falaram que não importava o que fizesse, se o encontrassem de novo com uma paranga de maconha ou com um maço de cigarros, iriam prendê-lo